



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

מס' תיק: 1/234/2014

**מפקח על רישום מקרקעין
ירושלים**

בפני כבוד המפקח הבכיר אורן סילברמן

התובעת:
החברה לניהול קופת התגמולים והפנסיה של
עובדי הסוכנות היהודית לא"י בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד מריאנה גיזונטרמן וזיוון אלימי
רחוב ז'בוטינסקי 7, רמת גן

- נ ג ד -

הנתבעת:
נ.ס.ד.ר. שירותים ואחזקות בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד עינת נוימרק
רחוב דרך בן גוריון 1, רמת גן

פסק דין

המחלוקת בהליך זה עניינה בשאלת הבעלות בזכויות הבניה בבית המשותף ברחוב שטראוס 10 ירושלים הבנוי כל חלקה 67 בגוש 30065.

מבוא וטענות הצדדים

1. הבית דנן נרשם כבית משותף בפנקס הבתים המשותפים ביום 12.11.70 ועל ניהולו חל תקנון מוסכם שנרשם.
2. התובעת הינה בעלת יחידה בקומה ראשונה בבית (יחידה בשטח 302 מ"ר לה צמודים 151/998 חלקים ברכוש המשותף) הרשומה כתת חלקה 21.
3. הנתבעת הינה בעלת יחידה בקומת הגג בבית (יחידה בשטח 34 מ"ר לה צמודים 165/998 חלקים ברכוש המשותף) הרשומה כתת חלקה 22. ליחידת הנתבעת הוצמד גג הבית בשטח של 297 מ"ר וכן נקבעו הוראות תקנוניות אשר מקנות לבעלי תת חלקה 22 זכות לעשות שינויים ופעולות בגג וכן במסמכי רישום הבית המשותף.
4. התובעת טוענת כי הנתבעת רשאית לממש בניה על הגג הצמוד ליחידתה בהיקף זכויות הבניה הנגזרות מחלקה היחסי ברכוש המשותף ולא תוך ניצול של כלל זכויות הבניה בבית, מבלי לקבל לשם כך את הסכמת כל בעלי היחידות בבית. כך, במקום בנייה של חצי קומה (על פי חלקה היחסי בזכויות) מבקשת הנתבעת לבנות 3 קומות נוספות אשר יכפילו את שטח הרצפות בבית. אין בידי הנתבעת הסכמה של בעלי הדירות (הנוכחיים או מכוח התקנון) למימוש כל זכויות הבניה בבית ואין בידה הסכמה כאמור להצמדת גג המבנה החדש ליחידתה. בנסיבות האמורות מבקשת התובעת כי ינתן פסק דין הצהרתי אשר יקבע כי זכויות הבניה בבית הינן רכוש משותף של בעלי הדירות וכי נדרשת הסכמתם לניצול הזכויות מעבר לחלק היחסי של יחידת הנתבעת ברכוש המשותף.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

מס' תיק: 1/234/2014

**מפקח על רישום מקרקעין
ירושלים**

5. הנתבעת טוענת כי על פי התקנון המוסכם החל הוצמדו לה כל זכויות הבניה בבית ורק היא זכאית לבנות על הגג הצמוד ליחידתה. לשון התקנון איננה כוללת כל הגבלה או צמצום ומנוסחת באופן רחב, שאינו מגביל את אפשרות מימוש הבניה המוחלטת שניתנה לנתבעת. כוונת רשות הפיתוח, אשר היא זו שרשמה את הבית המשותף, היתה להקנות בתקנון את מלוא הזכויות ליחידת הנתבעת, שאם לא כן לא היה כל צורך בהוראה הפרטנית והייחודית שנכללה בתקנון. ממילא הנתבעת גם רכשה במפורש מרשות הפיתוח את זכויות הבניה. גם ההוראה בתקנון אשר מקנה לנתבעת זכות לתקן את החלקים ברכוש המשותף, כתוצאה ממימוש זכויותיה בגג, מלמדת על הצמדה של מלוא זכויות הבניה ליחידתה. שאלת הצמדת הגג העליון בבנייה החדשה איננה רלבנטית להליך דנן - הבניה המבוקשת הינה אכן לשלוש קומות נוספות על פי זכויות הנתבעת בתקנון ואין כל מניעה כי הגג החדש יירשם כגג משותף.

6. אציין כי ראשיתו של ההליך בבקשה לצו מניעה זמני (תיק ב"ב 01/235/14) אשר הסתיימה בהסדר לפיו כסעד ביניים (מבלי להוות כל הודאה) לא תהא רשאית הנתבעת לבנות מעבר לזכויות הבנייה הנגזרות מחלקה היחסי ברכוש המשותף. בהתאם להסכמת הצדדים נקבע התיק, כבר באותו מועד, להגשת ראיות.

7. מטעם התובעת הוגש תצהירו של מר גיל לוי. מטעם הנתבעת הוגש תצהירו של מר דב קצנבלוגן. העדים נחקרו נגדית על תצהיריהם ביום 30.11.14. כן נשמעה עדותו של מר משה מזרחי - נציג רשות הפיתוח/עמידר. בנוסף הוגשה לתיק תעודת עובד ציבור חתומה על ידי מר ערן מוטר - מנהל תחום עסקאות ופרויקטים בחטיבת הנכסים של הסוכנות היהודית לא"י (להלן: "התע"צ").

8. עוד אעיר כי הליך זה נשמע במקור בפני כבוד המפקח הבכיר (כתוארו אז) שלומי הייזלר. עם מינויו של האחרון לתפקיד הממונה על המרשם הועבר התיק לדיון בפניי. לאור החלטתי מיום 15.02.16 והודעות הצדדים מיום 18.02.16 ו- 21.02.16 המשיך ניהול התיק מהשלב אליו הגיע המפקח הייזלר ללא צורך בשמיעה חוזרת של ראיות.

דיון והכרעה

9. ההכרעה הנדרשת בהליך זה עניינה בפרשנות הוראות התקנון המוסכם החל על הבית כאמור.

10. וידוגש, הצדדים אינם חלוקים בנוגע למשמעות המשפטית של "זכויות בניה" בבית משותף או למהותן הקניינית. המחלוקת היחידה הנדרשת להכרעה הינה האם הוקנו במסגרת התקנון המוסכם הזכויות האמורות ליחידת הנתבעת.

11. תקנון מוסכם הוא בבחינת הסכם שנחתם בין בעלי הדירות. מעצם רישומו של התקנון בפנקס הבתים המשותפים, ובהתאם להוראות סעיף 62(ג) לחוק המקרקעין, מקבל התקנון תוקף "קנייני" מחייב כלפי כל מי שהינו בעל דירה או מי שיהפוך לכזה בעתיד, כאילו היה האחרון צד לאותו הסכם מקורי.

12. לאור היות התקנון המוסכם הסכם כאמור הרי שכללי פרשנות, שיקולי הסבירות, המידתיות ותום הלב, המשמשים בניתוח ובפרשנות הסכמים ככלל, חלים גם על פרשנות תקנון מוסכם



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

מס' תיק: 1/234/2014

**מפקח על רישום מקרקעין
ירושלים**

(ר') סקירה בנוגע לדין הכללי ביחס לפרשנות הסכמים בע"א 3894/11 דלק - חברת הדלק הישראלית בע"מ נ' ניר בן שלום (פורסם בנבו) וכן ע"א 841/15 פנורמה הצפון חברה לבנייה בע"מ נ' פלוני (פורסם בנבו)).

13. אין מחלוקת בין הצדדים בנוגע למעמד המשפטי הכללי של זכויות בניה בבית משותף. עיון בסיכומיהן בכל הקשור ל"מחלוקת המשפטית" מלמד כי שתיהן מבקשות להסתמך, למעשה, על אותם פסקי דין והלכות הנוגעות לפרשנות תקנון מוסכם, ובפרט, בנוגע למימוש זכויות בניה, כאשר כל אחת מנסה לשייך או לאבחן את אותם המקרים לענייננו. המסקנה הברורה העולה מן ההלכות שאוזכרו (ואחרות) והמחלוקת שבין הצדדים הינה כי נסיבותיו הקונקרטיות של כל בית וכל תקנון (או מסמך הסכמי אחר) הן אלו אשר יביאו להכרעה הנדרשת על פי כללי הפרשנות כאמור. כך גם במקרה דנן.

לשון התקנון

14. לשון התקנון המוסכם דנן, אף שהינה רחבה בכל הקשור לזכויות בעלי תת חלקה 22 לביצוע עבודות שונות בגג הצמוד ליחידתם, איננה ברורה דיה באופן שיכול להביא לקבלת גרסתו של צד זה או אחר בהליך דנן על יסוד לשון התקנון בלבד.

15. כך, כטענת התובעת, אין אזכור במסגרת התקנון ל"זכויות הבניה" בבית או להיקף הזכות לבניה המוקנית לבעלים של תת חלקה 22, לא מבחינה כמותית ואף לא תוך הפניה או התייחסות למצב התכנוני (קיים או עתידי). אין גם התייחסות ל"רום הרקיע" (ר') בהשלכה ע"א 11965/05 עזבון המנוח מרדכי קליין נ' דוד שרון (פורסם בנבו) וכן ע"א 7156/96 שואעי נ' בכרך, פ"ד נג(1) 469.

16. מאידך, כטענת הנתבעת, הוראת התקנון רחבה מאד ומקנה זכות בידה של הנתבעת לעשות בשטח הגג הצמוד בכל עת "שנויים, תיקונים, תוספות, בנייה, הריסה וחיבור דרך קבע, וחיבור ארעי וכל שנוי אחר בגג וגם ברכוש המשותף של הבית" (סעיף 5 לתקנון), כל זאת ללא צורך בהסכמה של יתר בעלי היחידות בבית אשר נותנים את הסכמתם לביצוע האמור מראש. בנוסף מקנה התקנון זכות בידי בעלי תת חלקה 22 לתקן את צו רישום הבית המשותף כתוצאה מביצוע הפעולות על פי התקנון, לרבות, זכות לתקן את החלקים ברכוש המשותף, גם כן בהסכמה מראש של בעלי הדירות בבית (סעיף 6 לתקנון).

17. זאת ועוד. כשם שהוראת התקנון איננה קובעת הפניה כמותית לאפשרות מימוש הזכויות כאמור, הרי שהיא גם לא קובעת כל מגבלה שהיא (ר') בפרשת שואעי לעיל וכן ע"א 432/83 מזרחי נ' חביב פ"ד מ(4) 673.

18. בהקשר זה נכון יהיה להאיר, כבר עתה, כי מבין החלופות הפרשניות האפשריות לתקנון (על פי לשונו) הרי שבנסיבות דנן אי אפשר לקבל את טענת התובעת לפיה התקנון מקנה לבעלי תת חלקה 22 זכויות לבניה על פי חלקם היחסי בלבד ברכוש המשותף בלבד.

ראשית, זכויות בניה אינן בגדר "רכוש משותף" אלא נכס משותף של בעלי הדירות אשר נתון להסכמות חוזיות (ר') בהקשר זה בפרשת שואעי לעיל וכן ע"א 2139/12 שרה רוזן ו-49 א' נ' חברת ארזי הברכה (פורסם בנבו)).



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' תיק: 1/234/2014

מפקח על רישום מקרקעין
ירושלים

שנית, אין כל אזכור בתקנון להגבלת אפשרות הבניה על פי החלק היחסי. אין כל הפניה בתקנון לחלק היחסי ברכוש המשותף. ניסוח התקנון בכל הקשור לבניה על הגג רחב ומאפשר, לכל הפחות, בניה על כל שטח הגג, ללא כל קשר לחלק היחסי ברכוש המשותף.

19. לו בכך הייתה המחלוקת הרי שדי היה בלשון התקנון כדי להביא לדחיית התובענה. אולם, שעה שעסקינן במחלוקת אשר נוגעת לבניה בהיקף גדול יותר מאשר על מלוא שטח הגג הצמוד הרי שלאור אי שלמות ניסוח התקנון כאמור עלינו להתחקות אחר פרשנות התקנון מתוך בחינת ראיות חיצוניות לו, ובעיקר, את כוונת המנסחים.

אומד דעת הצדדים

20. לאחר ששקלתי את הראיות בהליך זה הרי שהקביעה הברורה המתבקשת היא כי הוכח על ידי הנתבעת שמלוא זכויות הבניה בבית, הקיימות על פי תוכנית מתאר 62, ואשר ניתנות למימוש על הגג הצמוד ליחידתה, הוצמדו בתקנון הבית המשותף הרישום לתת חלקה 22 וממילא לתובעת דנן אין כל זכות בהן.

21. ראשית, לשון התקנון נוטה יותר לקבלת פרשנות הנתבעת – הזכות המוקנית בתקנון איננה רק לבצע הרחבה או תוספת לקיים אלא גם לבצע "בנייה", "הריסה" ו- "כל שנוי אחר בגג וגם ברכוש המשותף של הבית". מדובר בהוראה רחבה בתקנון מוסכם, ודאי לתקופה בה נרשם התקנון האמור בשנת 1970. אין הגבלה על אפשרות הבניה, ובפרט לא תוך הפניה לחלק היחסי ברכוש המשותף. בכל הקשור למימוש זכות הבניה לשון התקנון הינה כמעט מוחלטת.

22. שנית, לא ניתן להתעלם מהעובדה כי הוראת התקנון מקנה זכות לבעלי תת חלקה 22 לתקן את צו רישום הבית המשותף ובכלל האמור "לתקן את החלקים ברכוש המשותף" (סעיף 6 לתקנון). תיקון החלקים ברכוש המשותף כאמור נדרש כאשר מבוצעת בניה אשר חורגת מעבר לחלקה היחסי של היחידה ברכוש המשותף. ויודגש, צודקת הנתבעת (בטענתה בסעיף 11 לסיכומיה שלא זכתה למענה מספק בהקשר זה בסיכומי התשובה או בכלל) כי בנסיבות בהן היתה מתקבלת פרשנות התובעת לתקנון הרי שמדובר היה בהוראה חוזית "מתה" - בניה על הצמדה על פי החלק היחסי ברכוש המשותף (אשר על פי צו הרישום חושב כאשר הוא כולל את שטח ההצמדה) איננה מצריכה תיקון החלקים ברכוש המשותף וספק אם בכלל מחייבת הסכמה מראש של בעלי הדירות (להבדיל ממשלוח הודעה) בהליך מנהלי לתיקון צו הרישום.

23. שלישית, על פי מסמכי רישום הבית המשותף רשות הפיתוח היא זו אשר חתמה על הבקשה לרישום הבית בפנקס הבתים המשותפים וגם נרשמה במסגרת אותו הרישום כבעלים של כל היחידות בבית. משכך, כוונתה ברישום הבית המשותף, פרשנותה את הוראות התקנון והתנהלותה בהקשר זה לאורך כל השנים הינן בעלות משקל מכריע בהכרעה הנדרשת.

24. מן הראיות שהוצגו בתיק זה עולה בבירור כי כוונת רשות הפיתוח היתה להצמיד את מלוא זכויות הבניה הקיימות בבית על פי המצב התכנוני באותה עת לתת חלקה 22.

כך עולה מעדות מר מזרחי, נציג רשות הפיתוח, אשר מעיד כי "גם בתקנון הבית המשותף מופיע שכל זכויות הבניה צמודות לתת חלקה 22" (עמוד 2 לפרוטוקול שורות 38-39).



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' תיק: 1/234/2014

מפקח על רישום מקרקעין
ירושלים

כך עולה ממכתבים שונים אשר צורפו לתע"צ - במכתב מיום 15.11.66, עוד בטרם רישום הבית המשותף, התייחסות רשות הפיתוח הינה ליחידה בקומת הגג אליה צמוד "הגג יחד עם הזכויות לבנות שתי קומות נוספות"; במכתב מיום 03.12.70, בסמוך לאחר רישום הבית המשותף מיום 12.11.70, ההתייחסות הינה ליחידה בקומת הגג אליה "צמוד הגג יחד עם זכויות לבנות 2 קומות נוספות"; במכתב מיום 09.1.77 מתייחסת רשות הפיתוח למכרז למכירת "החדרים על הגג וזכויות הבנייה עליו"; במכתב מיום 09.10.77 מתייחסת, שוב, רשות הפיתוח לתת חלקה 22 כיחידה אליה "יוצמדו הגג וזכויות הבנייה"; גם בתרשומת פרטים מיום 31.12.75 בעקבות ביקור במקום של נציגי רשות הפיתוח והסוכנות מוגדרת היחידה "2 חדרים (כיום כזה גדולה) אליהם צמוד הגג עם זכויות לבנות שתי קומות נוספות". יוצא כי גם לפני רישום הבית המשותף וגם לאחריו ראתה רשות הפיתוח את הזכות לבנות שתי קומות נוספות על גג הבית כצמודה ליחידה על הגג – תת חלקה 22.

25. יוער כי, אומנם, במכתבים נוספים שצורפו לתע"צ, נעשתה הבחנה מסוימת בין היחידה על הגג לבין זכויות הבניה. אולם, עיון במסמכים אלו מלמד כי הדבר נעשה אך במסגרת מו"מ שנוהל בין רשות הפיתוח לבין הסוכנות היהודית, המחזיקה בנכסים, לרכישת הנכסים על ידי האחרונה, מאחר והסוכנות לא היתה מעוניינת ברכישת זכויות הבניה. בסופו של יום גם את היחידות בגג לא רכשה הסוכנות היהודית (שעה שלא התקבל אישור ועדת העיסקות של מינהל מקרקעי ישראל למכירה זו), והיה עליה לפנות על פי הסכם אליו הגיעה עם רשות הפיתוח (כפי שעולה מהמכתבים הנ"ל מיום 09.01.77 ומיום 09.10.77 וכן ממכתב נוסף מיום 28.10.77), הרי שנותרה הצמדת הזכות לבנות שתי קומות נוספות בבית צמודה ליחידת הגג – תת חלקה 22.

26. מן הראיות עולה גם כי זכויות הבניה נמכרו בפועל לנתבעת על ידי רשות הפיתוח, היא הבעלים של כל הזכויות בבית במועד רישום הבית המשותף, היא לבדה גם זו אשר ביצעה את אותו הרישום כאמור.

כך עולה מעדותו המפורשת של מר מזרחי בכל הקשור לזכויות שנמכרו לנתבעת – המכרז התבסס על חוות דעת תכנונית אשר כללה התייחסות לזכויות בניה קיימות (עמוד 2 לפרוטוקול שורה 11 וכן מוצג נ/1), גם השומה שנערכה בהקשר זה, לבד מכך שהתבססה על חוות הדעת התכנונית, התבססה גם על חוות דעת משפטית לפיה אין מניעה למיצוי זכויות בנייה (ר' עמוד 2 שורות 3-4 וכן מוצג נ/2). לבסוף ישנה גם התייחסות מפורשת של מר מזרחי כי זכויות הבניה נמכרו לנתבעת, על פי השומה (עמוד 2 שורה 43 ועמוד 3 שורה 10).

כך מחוות הדעת התכנונית (מוצג נ/1) והשומה (מוצג נ/2) אשר התייחסו, בין היתר, במפורש ל"אפשרויות הבניה הזמינות על גג לפי תכנית המתאר הקיימת".

וידגש, לא יכולה להיות מחלוקת כי המחיר שבו רכשה התובעת את זכויותיה משקף גם רכישה של זכויות הבניה. מעבר לכך שהדברים עולים במפורש מעדות נציג רשות הפיתוח הרי שגם השומה מטעם הרשות ועדותו של מר קצנלבוגן (ר' סעיף 9 לתצהירו ועמוד 6 לפרוטוקול שורות 20-23) תומכים באמור.

לכאורה, קבלת טענת התובעת משמעה כי רשות הפיתוח רימתה את הנתבעת, כך ממש, ואולי אף בצורה מכוונת, להציע מחיר גבוה תמורת זכויות שהיא לא התכוונה כלל למכור לה, והכל



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

מס' תיק: 1/234/2014

**מפקח על רישום מקרקעין
ירושלים**

תוך הפניה בתנאי המכרז למסמכי רישום הבית המשותף. את האמור לא עלה בידי התובעת להוכיח.

27. רביעית, מחוות הדעת התכנונית והשמאות עולה כי מדובר בזכויות בניה מכח תוכנית מתאר 62 מיום 16.07.59 ועל פיה. כאמור, הבית נרשם בפנקס הבתים המשותפים ביום 12.11.70. בהתאם, הרי שבמועד רישום הבית המשותף בפנקסים היה ידוע וברור לרשות הפיתוח בדבר קיומן של זכויות בניה נוספות, ובכלל האמור האפשרות לבניית שתי קומות נוספות בבית. האמור גם עולה במפורש מהמכתבים המוזכרים לעיל. בנסיבות שכאלו ניתן להסיק עובדתית כי הקביעה המרחיבה בתקנון בדבר אפשרות הבניה על הגג, שאיננה כוללת כל הסתייגות או הגבלה על היקפה, ודאי בהתחשב בכך שמדובר בתקנון אשר נרשם עוד בתחילת שנות ה-70 של המאה הקודמת, נועדה להקנות את מלוא הזכויות הקיימות והידועות (ובמיוחד בניית שתי קומות נוספות) ליחידת הגג אשר נרשמה כתת חלקה 22.

28. חמישית, הוכח בפניי כי לתובעת, בכל מקרה, אין כל חלק בזכויות לבניית שתי קומות נוספות על גג הבית לאור ויתור מפורש על זכויות אלו. ובמה דברים אמורים.

אין חלוקת את כי הזכויות בנכסי התובעת בבית היא קיבלה במסגרת הסכם העברת נכסים בינה לבין הסוכנות היהודית (עמוד 4 שורות 12-13). יוער, באמרת אגב, כי לא עלה בידי התובעת להציג הסכם קונקרטי בנוגע לנכס הנדון (ר' שם וכן בעמוד 1 לפרוטוקול שורה 34). אין מחלוקת כי הסוכנות היהודית רכשה את הזכויות בנכס מרשות הפיתוח (עמוד 4 שורות 18-19).

מהמסמכים אשר צורפו לתע"צ עולה כי הסוכנות החזיקה בחלקים במבנה הנדון ונוהל מו"מ בינה לבין רשות הפיתוח לרכישת הזכויות בנכסים בהם החזיקה. במסגרת המו"מ שנוהל בין הצדדים הוצע לסוכנות לרכוש גם את היחידה על גג הבית אליה צמוד הגג וכן הזכויות לבניית שתי קומות נוספות. הסוכנות הודיעה מפורשות כי היא איננה מעוניינת לרכוש את זכויות הבניה על הגג, היא איננה מתנגדת למכירת הזכויות לאחרים והיא מבקשת לרכוש רק את הנכסים התפוסים על ידי (ר' מכתבים חתומים על ידי מר זהבי מיום 6.1.76 ומיום 17.8.77 וכן התייחסות בכתב יד מיום 12.08.77 ע"ג מכתב רשות הפיתוח מיום 11.07.77 והתייחסות בכתב יד מיום 5.11.76 ע"ג תרשומת בעקבות ביקור במקום מיום 31.12.75). דא עקא, ועדת העיסוק של מינהל מקרקעי ישראל דחתה בקשה זו (כפי שפורט לעיל) ובהתאם לא רק שהסוכנות לא רכשה את הזכויות ביחידות על הגג אלא היא אף קיבלה דמי-פינוי בגין סילוק ידה מתת חלקה 22 (ר' מכתב מיום 28.10.77).

ויוער, מן המסמכים עולה כי נעשה ניסיון על ידי רשות הפיתוח לאפשר רכישת הזכויות בנכסים המוחזקים בלבד, בלי זכויות הבניה, ובכלל האמור אף נשקלה אפשרות להפריד בין השניים (ר' מכתב רשות הפיתוח מיום 31.3.76 המדבר על עריכת מכרז לגג). אולם, בסופו של דבר נותרו החדרים על הגג "עם הגג וזכויות הבניה עליו" כמקשה אחת (ר' מכתב מיום 9.1.77), כפי שכבר נרשם במסגרת צו הרישום והתקנון המוסכם שלא תוקנו מעולם.

יוצא, אם כן, כי הסוכנות ידעה בדבר קיומן של זכויות בניה בבית אשר צמודות ליחידה על הגג (שכבר נרשמה כתת חלקה 22). היא ויתרה במפורש ובמודע, לרבות בכתב בצורה רשמית, על האפשרות לרכוש איזה חלק מזכויות הבניה האמורות. למעלה מכך, היא אף



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' תיק: 1/234/2014

מפקח על רישום מקרקעין
ירושלים

ביקשה להפריד את זכויות הבניה מיחידות הגג ובקשתה נדחתה. הסוכנות פינתה את חזקתה ביחידות הגג (אליהן צמודות זכויות הבניה) ואף קיבלה דמי פינוי – מכלול ההתנהלות האמורה מלמד כי בידה של הסוכנות ממילא אין כל חלק בזכויות לבניית שתי קומות נוספות על גג הבית, זהו התנאי לעצם רכישת זכויותיה של האחרונה בבית, וכפי שכתוב במפורש בהודעה על אישור העסקה מיום 9.10.77 – "צו העסקה כפופה לפינוי יח' מס' 22 שאליה יוצמדו הגג וזכויות הבניה. סכום הפנוי כי שייקבע ע"י עדת פנויים במשרדנו יקוזז מהמחיר".

29. לאור האמור הרי שבנסיבות בהן הדיון נסוב סביב שאלת זכויות הבניה בבית, הכפופות להסכמות חוזיות, לרבות, ויתור (ר' הפניות לעיל), ממילא לא יכולה להישמע כל טענה מצד הסוכנות כי לה זכאות כלשהי בנוגע לזכויות הבניה בבית עליהן ויתרה במפורש כתנאי לרכישת זכויות בבית. התובעת, כחליפתה של הסוכנות, איננה יכולה להישמע בכל טענה אחרת, ודאי כאשר "רכשה" הזכויות במסגרת העברת זכויות לא ברורה בין הסוכנות לבניה וכאשר אפילו אין בידה להציג הסכם רכישה כאמור.

30. שישית, אין בידי לקבל את הטענה כי תנאי המכרז במסגרתו רכשה הנתבעת את הזכויות לא נכללה הזכות לממש את הבניה המבוקשת על ידי הנתבעת.

אומנם, בסעיף 6 לתנאי המכרז נכתב כי לא מוצעות זכויות בניה במכרז. אולם, הסעיף האמור עומד בסתירה מהותית להוראות אחרות - בפרטי המכרז עצמו (ר' למשל סעיפים 2.3, 2.7 ו-2.8 לתנאי המכרז); בשומה אשר שימשה יסוד להערכת השווי למחיר המינימום במכרז (ר' מוצגים 1/1 ו-2/1 וכן עדות מר מזרחי בעמוד 43-42); בתקנון המוסכם, שהרי גם על פי פרשנות התובעת ישנן זכויות בניה בבית אשר ניתנות למימוש (על פי החלק היחסי ברכוש המשותף לשיטתה) ולכאורה גם אלו, לאור פרשנותה את תנאי המכרז, כלל לא נמכרו; לכך שהתקנון מקנה זכויות נרחבות למימוש על הגג, וכיצד ניתן לבצע את אלו ללא מכירה של זכויות הבניה עצמן?; לעדותו הברורה של מר מזרחי לפיה נמכרו זכויות בניה (ר' הפניות לעיל); להסכם המכר שנחתם (ר' מחיר המכירה וכן סעיף 1.1. המגדיר את זכויות הבניה הנדונות מכוח תוכנית מתאר 62 וסעיף 15 להסכם).

בנסיבות אלו הפרשנות היחידה אשר ניתן לייחס לסעיף האמור בתנאי המכרז הינה כי לבד מהזכות לבנות אשר הוקנתה על פי התקנון, קרי, על פי המצב התכנוני הקיים לפי תוכנית מתאר 62 כמפורט בהרחבה לעיל, לא נמכרו "זכויות בניה" נוספות.

31. שביעית, אומנם, אין התקנון מקנה זכות בידי הנתבעת להצמיד ליחידתה את הגג החדש אשר ייבנה במסגרת העבודות המבוצעות על ידה. בהקשר זה צודקת התובעת כי הוראה כאמור איננה נכללת בתקנון, אף לא במשמע. למעשה, גם הנתבעת איננה חולקת על האמור (ר' סעיף 39 לכתב ההגנה) ובהתאם ניתן לקבוע כי הגג החדש שיווצר כתוצאה מהבניה הינו רכוש משותף ויירשם ככזה.

אולם, העדרה של הוראה כאמור לעניין הצמדת גג הבית החדש אין בה למנוע את הבניה המבוקשת, אף שמדובר בתוספת קומות.

ראשית, כאמור לעיל, הזכות על פי התקנון היא רחבה ואיננה כוללת הגבלה על אפשרות מימוש הבניה בקומה אחת או קומות נוספות. הלשון הרחבה יכולה לכלול גם בניה, בהינף



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

מס' תיק: 1/234/2014

**מפקח על רישום מקרקעין
ירושלים**

אחד, ביותר מקומה אחת. ויודגש, לא תבוצע הבניה בהינף אחד הרי שלא תוכל עוד הנתבעת לבצע בניה נוספת בבית בהעדר הצמדה של הגג החדש ליחידתה.

שנית, כאמור, כוונת מנסחת התקנון היתה להצמיד ליחידה את מלוא זכויות הבניה הקיימות, אשר כבר באותו מועד היה ידוע כי מדובר, בין היתר, על תוספת של שתי קומות. זכויות אלו הוקנו לתת חלקה 22 במפורש על ידי רשות הפיתוח.

שלישית, הנתבעת רכשה את הזכות לבניית שתי קומות נוספות בבית ומאידך קודמתה של התובעת בזכויות ויתרה במפורש על כל זכות בהקשר זה כתנאי לרכישת זכויותיה בבית.

32. לאור כל האמור לעיל עולה כי לבעלי תת חלקה 22 הזכות לבנות על גבי הגג הצמוד ליחידה תוך מימוש זכויות הבניה המוקנות מכוח תוכנית מתאר 62, לרבות, הזכות להוסיף קומות ויחידות לבית.

33. ויודגש, הזכות מכוח תוכנית מתאר 62 כוללת גם את הזכות לממש בניה מכוח זכויות נלוות לתוכנית בהתאם להוראות דיני התכנון ובניה, לרבות, הקלות לאותה תוכנית ככל שניתן לאשרן במסגרת התכנונית המתאימה. ברי כי בהקשר התכנוני, לרבות ביחס להקלות, נשמרת זכותה של התובעת להתנגד בהליכים המתאימים. אולם, על פני הדברים, מתוך הבקשה להיתר הבניה שצורפה על ידי התובעת (ר' נספח ד' לתצהיר לוי), מדובר בבניה מבוקשת מכוח תוכנית מתאר 62 כאמור.

סיכום

34. לאור כל האמור אני קובע כי במסגרת תקנון הבית המשותף הוקנתה לבעלי תת חלקה 22 הזכות לממש בניה על גג הבית בהתאם למצב התכנוני המאושר על פי תוכנית מתאר 62, לרבות, זכויות נלוות מכוח התוכנית ודיני התכנון והבניה, וזאת בהסכמה "קניינית" מראש של כל בעלי הדירות בבית.

35. בהתאם, ומשעה שהבקשה לבניה נושא הדיון הינה מכח תוכנית מתאר 62 הרי שיש מקום לדחות את התביעה.

36. למען הסר ספק יובהר כי בעלת תת חלקה 22 רשאית לבצע את הבניה בהינף אחד, שכן, בגמר הבניה הגג החדש יותר רכוש משותף.

37. בנסיבות אלו צו המניעה מיום 07.09.14 בתיק ב"ב 01/235/14 בטל.

38. סיכום ההלכה בנוגע לפסיקת הוצאות היא כי "באין נסיבות מיוחדות, המצדיקות לשלול מבעל-דין שזכה את הוצאותיו, יהא אותו בעל-דין זכאי לפסיקת הוצאות. אופן ניהול הדיון על-ידי בעלי הדין, הוא אחד השיקולים שניתן להביא בחשבון בעת הטלת ההוצאות. העובדה בלבד, כי בעל-דין פעל בתום-לב, כטענתו, אין בה כדי לפטור אותו מהוצאות הנפסקות למי שמפסיד בדינו. בעל-דין שזכה בדין זכאי, כי שכרו לא ייצא בהפסדו וממילא זכאי הוא להוצאותיו" (א. גורן סוגיות בסדר דין אזרחי (מהדורה חמישית, תשנ"ט) בעמ' 533).



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

מס' תיק: 1/234/2014

**מפקח על רישום מקרקעין
ירושלים**

39. אף אם התובענה מקורה במחלוקת פרשנית בנוגע להוראות התקנון המוסכם, אין בכך הצדקה מדוע תצא הנתבעת בחסרון כיס שעה שזכתה בדין.

40. אני מחייב את התובעת לשלם לנתבעת בגין החזר הוצאות ניהול ההליך, כולל שכ"ט עו"ד והוצאות אחרות, סך כולל של 12,000 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד למועד התשלום בפועל.

41. פסיקת גובה החזר ההוצאות התחשבתי בכך שהוגשה בקשה לסעד זמני, נערך דיון אחד במסגרתו הגיעו הצדדים להסכמה, הוגשו תצהירים, נערך דיון הוכחות והוגשו סיכומים בכתב.

המזכירות תשלח לצדדים העתק פסק הדין בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתן בלשכתי היום כ"ב תמוז תשע"ו, 28 יולי 2016, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח בכיר על רישום מקרקעין
ירושלים